

Kurzkommentar Obligationenrecht I

Vor Art. 41 – 61 OR

NICOLA MOSER/BEAT SCHÖNENBERGER, in:
Isabelle Wildhaber, Daniel Häusermann, Heinrich Honsell
Obligationenrecht
2. Auflage, 2026
Helbing Lichtenhahn Verlag, ISBN 978-3-7190-4182-3

Vorbemerkungen zu Art. 41–61

LITERATUR

BÜHLER, Geschichte des schweizerischen Obligationenrechts, Zürich 2023; DERS., Ist die Schadensprävention kein Thema für das schweizerische Haftpflichtrecht?, in: FS Rey, Zürich 2003, 197 ff.; BUSSANI, Les relations entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, in: Foëx/Werro (Hrsg.), La réforme du droit de la responsabilité civile, Zürich 2004, 109 ff.; DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, 2. Aufl. Bern 1982; FELLMANN/KOTTMANN, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bd. I: Allgemeiner Teil sowie Haftung aus Verschulden und Persönlichkeitsverletzung, gewöhnliche Kausalhaftungen des OR, ZGB und PrHG, Bern 2012; HACHEM, Prävention und Punitive Damages, in: Wolf/Mona/Hürzeler (Hrsg.), Prävention im Recht, Basel 2008, 197 ff.; HONSELL, Der Strafgedanke im Zivilrecht – ein juristischer Atavismus, in: FS Westermann, Köln 2008, 315 ff. (zit. FS Westermann); HONSELL/ISENRING/KESSLER, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 5. Aufl. Zürich 2013; KELLER, Haftpflicht im Privatrecht, Bd. I, 6. Aufl. Bern 2002 (zit. I); KELLER/GABI/GABI, Haftpflichtrecht, 3. Aufl. Basel 2012; KRAMER, «Reine Vermögensschäden» als Folge von Stromkabelbeschädigungen, recht 1984, 128 ff.; LOACKER, Gefährdungshaftung und ununterbrochener Kausalzusammenhang, recht 2023, 11 ff.; LORANDI, Haftung für reinen Vermögensschaden, recht 1990, 19 ff.; MÜLLER, La responsabilité civile extracontractuelle, 2. Aufl. Basel 2023 (zit. Responsabilité); MÜLLER-CHEN, Probleme des dualistischen Haftungskonzepts, in: Fellmann (Hrsg.), Der Haftpflichtprozess 2008, Zürich 2008, 13 ff.; DERS., Haftpflichtrecht in der Krise?, BJM 2002, 289 ff.; OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bd. I, Allgemeiner Teil, 5. Aufl. Zürich 1995 (zit. I); DIES., Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bd. II/1, Besonderer Teil, 4. Aufl. Zürich 1987 (zit. II/1); DIES., Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bd. II/2, Besonderer Teil, 4. Aufl. Zürich 1989 (zit. II/2); REY/WILDHABER, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 6. Aufl. Zürich 2024; ROBERTO, Haftpflichtrecht, 2. Aufl. Bern 2018 (zit. Haftpflichtrecht); DERS., Verschuldenshaftung und einfache Kausalhaftungen: eine überholte Unterscheidung?, [AJP 2005, 1323 ff.](#); SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 2. Aufl. Zürich/Basel/Genf 2013; SCHÖNENBERGER, Generalklausel für die Gefährdungshaftung – ein sinnvolles Reformvorhaben?, in: Festgabe Schweizerischer Juristentag 2004, Basel/Bern 2004, [\[Seite 207\]](#) 171 ff.; SCHWENZER/MÜLLER-CHEN, Rechtsvergleichung, Fälle und Materialien, Tübingen 1996; WIDMER, Anything goes – Haftpflichtrecht im Offside, [HAVE 2014, 363 ff.](#)

I. Begriff, Funktion und Quellen des Haftpflichtrechts

Die Art. 41–61 (zweiter Abschnitt des ersten Titels der ersten Abteilung) sind mit **1**
«**Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen**» betitelt. Damit behandelt der zweite Abschnitt die **unerlaubten Handlungen** als zweiten Entstehungsgrund einer Obligation, nach dem Vertrag im ersten Abschnitt und vor der ungerechtfertigten Bereicherung im dritten Abschnitt. Nach heutiger Sprachregelung sind die Begriffe **ausservertragliches Haftpflichtrecht** und **Deliktsrecht** Synonyme zum Begriff der **unerlaubten Handlung** (vgl. REY/WILDHABER, N 4). Auch der Begriff des **Haftpflichtrechts** (*responsabilité civile*) bezeichnet i.e.S. die **ausservertragliche Einstandspflicht für Schädigungen Dritter** (vgl. ROBERTO, Haftpflichtrecht, N 02.07; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 N 2). Im weiteren Sinne fällt auch die **vertragliche Haftung** darunter (KELLER/GABI/GABI, 2). Der Unterschied zeigt sich neben den

Haftungsvoraussetzungen insb. bei den Haftungsmodalitäten (Verjährung, Beweislastumkehr, Hilfspersonenhaftung).

Das ausservertragliche Haftpflichtrecht regelt die Ansprüche, die infolge einer Rechtsgutsverletzung entstehen. Inhalt einer derart entstandenen Obligation ist ein Wiedergutmachungsanspruch gegenüber dem Verletzer (REY/WILDHABER, N 11). Dieser Wiedergutmachungsanspruch besteht in einem **Schadenersatzanspruch** oder einem Anspruch auf **Ersatz für immaterielle Unbill** (Genugtuung). Das Haftpflichtrecht regelt damit nicht nur den Schadensausgleich (so aber die h.L., vgl. z.B. HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 N 4; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 49.01), sondern auch Ansprüche für den Ausgleich nicht ersatzfähiger Schädigungen (immaterielle Unbill). Bei genauer Betrachtung kann eine unerlaubte Handlung neben diesen Ersatzforderungen auch weitere Ansprüche, wie diejenigen auf Beseitigung einer Störung oder auf Unterlassung weiterer Störungen, auslösen (i.d.S. VON TUHR/PETER, OR AT, 407). Damit sind insb. alle Ansprüche aus **Persönlichkeitsverletzung** Teil des ausservertraglichen Haftpflichtrechts. Der Schadensausgleich und der damit verbundene Schadenersatzanspruch stellen aber zweifelsohne die praktisch bedeutendste Rechtsfolge im Rahmen der ausservertraglichen Haftpflicht dar. Die Entstehung einer solchen Obligation aus Deliktsrecht setzt nicht voraus, dass vor der Verletzungshandlung zwischen den Parteien ein Rechtsverhältnis besteht (REY/WILDHABER, N 3). Umgekehrt verhindert das Bestehen einer solchen Rechtsbeziehung – insb. eines Vertragsverhältnisses – die Entstehung einer deliktsrechtlichen Obligation nicht. Vielmehr konkurrenzieren ausservertragliche und vertragliche Haftpflichtansprüche miteinander (vgl. hierzu N 11).

[Seite 208] Entsprechend der vorerwähnten Bedeutung des Schadenersatzanspruches wird die Funktion des Haftpflichtrechts von der h.L. gemeinhin im **Schadensausgleich** gesehen (vgl. REY/WILDHABER, N 11; FELLMANN/KOTTMANN, N 3). Demnach bezweckt das Haftpflichtrecht den Ausgleich der durch eine Rechtsgutsverletzung entstandenen ökonomischen Nachteile. Damit einher geht das Bereicherungsverbot, wonach der Geschädigte nicht mehr ersetzt erhalten soll als den durch das schädigende Ereignis eingetretenen ökonomischen Schaden. Diese Ausgleichsfunktion des Haftpflichtrechts wird heute auch durch kollektive Schadensabnahmesysteme (insb. Versicherungen) wahrgenommen (vgl. FELLMANN/KOTTMANN, N 6).

Die neuere Lehre betont im Zusammenhang mit dem Haftpflichtrecht jedoch zunehmend auch die Bedeutung der **Prävention** (vgl. zum Gedanken der Generalprävention im Schadensrecht etwa HACHEM, 198 ff.). Das Haftpflichtrecht soll demnach auch die Aufgabe haben, einen Anreiz dafür zu schaffen, dass Dritte aufgrund eines Verhaltens nicht geschädigt werden (FELLMANN/KOTTMANN, N 3). Dabei ist zu unterscheiden zwischen der Verhinderung von Rechtsgutsverletzungen (Schädigungen) und der Verhinderung ökonomischer Nachteile (Schäden). Das Ziel der Verhinderung von Schäden ist sicherlich eine tatsächliche Folge des Haftpflichtrechts, da potenzielle Schadenszufügungen regelmässig in eine betriebliche Kostenrechnung einfließen und durch Haftpflichtversicherungen abgedeckt werden (vgl. m.N. auch SCHÖNENBERGER, 172). Die Verhinderung von Rechtsgutsverletzungen (z.B. Körperverletzungen) ist wohl schwieriger zu erreichen. Am bedeutsamsten dürfte sie im Bereich der Persönlichkeitsverletzungen oder bei der Verhinderung von Verletzungen von Immaterialgüterrechten sein.

Nach traditioneller Auffassung kommt dem Haftpflichtrecht hingegen **keine Straffunktion** zu (FELLMANN/KOTTMANN, N 3). Pönale Erwägungen sind in einem Recht unter Gleichgestellten systemfremd, «weil sie die Funktionszuteilung zum Strafrecht nicht beachten» (HONSELL, FS Westermann, 317). Aus diesem Grunde ist in der Schweiz die Zusprechung von Strafschadenersatz (nach dem Muster der US-amerikanischen *punitive damages*) nicht zulässig (vgl. ROBERTO, Haftpflichtrecht, N 02.79; MÜLLER, Responsabilité, N 6). Teilweise wird in diesem Zusammenhang in der

Lehre krit. bemerkt, dass die Möglichkeit der Reduktion des Schadenersatzbetrages bei geringem Verschulden entsprechend inkonsequent ist (vgl. ROBERTO, Haftpflichtrecht, N 02.83; a.A. ZK-OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 43 OR N 2; diff. REY/WILDHABER, N 17; vgl. hierzu Art. 43 N 9 f.).

Gesetzlich geregelt ist das Haftpflichtrecht einerseits in den Art. 41–61 OR, andererseits im ZGB (z.B. Art. 333, 679 ZGB) sowie in Spezialgesetzen (wie z.B. im PrHG, KHG, RLG, USG, GTG, SVG, LFG, StSG und EleG). Letztere spielen insb. im Zusammenhang mit Gefährdungshaftungen eine wichtige Rolle. [Seite 209] Auch andere Gesetze können vereinzelte Haftpflichtbestimmungen enthalten (vgl. z.B. Art. 273 SchKG).

6

II. Arten ausservertraglicher Haftung

Das Haftpflichtrecht unterscheidet traditionellerweise zwischen zwei Arten von Haftungen, der **Verschuldenshaftung** und der verschuldensunabhängigen **Kausalhaftung** (vgl. nur HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 N 8; KELLER/GABI/GABI, 3). Während bei der Verschuldenshaftung ein Anspruch nur entstehen kann, wenn der Schädiger vorsätzlich oder fahrlässig handelt, wird bei Kausalhaftungen auf das Verschuldenserfordernis verzichtet (krit. zum Begriff der Kausalhaftung SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 49.09; vgl. zum Verschuldensbegriff Art. 41 N 29 ff.). Die Verschuldenshaftung wird nach traditioneller Auffassung immer noch als die Regel betrachtet, wohingegen die Kausalhaftung die Ausnahme darstellen soll (vgl. HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 N 9, 13; REY/WILDHABER, N 76). Die Kausalhaftungen werden ihrerseits unterteilt in sog. **einfache** (gewöhnliche, milde) **Kausalhaftungen** und **Gefährdungshaftungen** (auch strenge, scharfe Kausalhaftungen genannt). Demnach kann im ausservertraglichen Bereich von drei Haftungsarten gesprochen werden (REY/WILDHABER, N 71; CR CO I-WERRO/PERRITAZ, N 3). Als weitere Unterkategorie der Kausalhaftungen werden tlw. die sog. kausalen Freistellungshaftungen als besondere Art der Staatshaftung erwähnt (vgl. OFTINGER/STARK, I, § 1 N 42).

7

Die **Verschuldenshaftung** geht vom Prinzip aus, dass eine Haftung nur dann Platz greift, wenn dem Schädiger ein Verschulden in Form von Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorgeworfen werden kann. Wie die übrigen Haftungsvoraussetzungen (vgl. hierzu Art. 41) ist das Vorliegen des Verschuldens von der geschädigten Partei gem. Art. 8 ZGB zu beweisen. Dieses Haftungsprinzip der Verschuldenshaftung ist insb. in der deliktsrechtlichen Grundnorm von Art. 41 Abs. 1 verwirklicht.

8

Einfache (gewöhnliche, milde) **Kausalhaftungen** knüpfen zur Haftungs begründung zwar nicht an ein Verschulden, wohl aber an eine Ordnungswidrigkeit oder an eine Unregelmässigkeit an. Dabei kann es sich um eine Sorgfaltsverletzung, einen Werk- oder Sachmangel oder um eine Eigentumsüberschreitung handeln (REY/WILDHABER, N 89). Einfache Kausalhaftungen werden von der h.L. mithin als **verschuldensunabhängige Haftungen** betrachtet (REY/WILDHABER, N 90; KELLER/GABI/GABI, 7; DESCHENAUX/TERCIER, § 2 N 35 f.). Zu den einfachen Kausalhaftungen zählen namentlich die Geschäftsherrenhaftung (Art. 55 Abs. 1), die Tierhalterhaftung (Art. 56 Abs. 1), die Werkeigentümerhaftung (Art. 58 Abs. 1), die Haftung für kryptografische Schlüssel (Art. 59a) sowie die Haftung des Urteilsunfähigen (Art. 54). Des Weiteren sind auch die Haftung des Familienhauptes (Art. 333 ZGB), die Grund [Seite 210] eigentümerhaftpflicht (Art. 679 ZGB) und – zumindest in Teilbereichen – die Produktheftpflicht gemäss PrHG zu zählen (REY/WILDHABER, N 1050, 1051, 1052). Obschon ein Verschulden nicht vorgesehen ist, kann sich der Schädiger bei den meisten einfachen Kausalhaftungen durch einen Sorgfaltsbeweis entlasten, namentlich bei Art. 55 Abs. 1, Art. 56 Abs. 1, Art. 59a Abs. 2 sowie Art. 333 ZGB. Aus diesem Grunde werden die einfachen Kausalhaftungen von einem Teil der Lehre als **Verschuldenshaftungen mit umgekehrter Beweislast** betrachtet (so etwa SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 49.09, HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1

9

N 23, ROBERTO, Haftpflichtrecht, N 02.22; DERS., [AJP 2005, 1323, 1329](#); SCHÖNENBERGER, 174; **a.A.** REY/WILDHABER, N 1044, diff. FELLMANN/KOTTMANN, N 666 ff.). Das BGer betrachtet diese Qualifikationsfrage als von lediglich dogmatischer, nicht aber praktischer Bedeutung ([BGE 131 III 115 E. 2.1](#)).

Als eigentliche verschuldensunabhängige Haftungen setzen Gefährdungshaftungen **10** weder ein Verschulden noch sonst eine Ordnungswidrigkeit oder Unregelmässigkeit voraus (REY/WILDHABER, N 1501). Gefährdungshaftungen knüpfen einzig an die besondere Gefährlichkeit einer Anlage, eines Betriebes oder einer Tätigkeit an (REY/WILDHABER, N 1502). Bei solchen gefahrenträchtigen Aktivitäten besteht regelmässig die Gefährdung, dass dadurch häufige und/oder sehr schwere Schädigungen hervorgerufen werden können (vgl. REY/WILDHABER, N 1500, SCHÖNENBERGER, 176, jeweils m.w.N.). Ob den Schädiger ein Vorwurf trifft, ist bei der Gefährdungshaftung irrelevant. Sie hat lediglich den Ersatz des Geschädigten im Auge, indem sie einen Ausgleich für die Duldung einer gesamtwirtschaftlich betrachtet zwar wünschenswerten, aber gefährlichen Tätigkeit vorsieht. Wie weit dieser Zweckgedanke geht, zeigt sich etwa an einem jüngeren Urteil des BGer, in welchem die SBB für eine Drittperson zu haften hatte, welche einen wartenden Passagier vor einen Zug stiess ([BGer 4A_602/2018](#)). Einzig dann, wenn eine sog. Unterbrechung des Kausalzusammenhangs vorliegt durch höhere Gewalt, grobes Drittverschulden oder grobes Selbstverschulden, kann der Schädiger sich bei einer Gefährdungshaftung entlasten (vgl. Art. 41 N 16). Die Lehre plädiert jedoch für eine zurückhaltende Anwendung dieser Rechtsfigur, zumal deren Existenzberechtigung in Frage gestellt wird (vgl. etwa LOACKER, 11 ff.). Der erwähnte Entscheid des BGer belegt, dass auch die Rsp. hohe Anforderungen an die Unterbrechung des Kausalzusammenhangs stellt. Am ehesten wird ein Unterbruch der Kausalität in der Konstellation des groben Selbstverschuldens anerkannt (so etwa jüngst in [BGer 4A_179/2021](#) betr. Haftung für einen Tramunfall). In der Schweiz finden sich Gefährdungshaftungstatbestände ausschliesslich in Sondergesetzen. Im Gegensatz zur allg. Verschuldenshaftung von Art. 41 Abs. 1 fehlt eine entsprechende allgemeine Generalklausel. Zu den wichtigsten Gefährdungshaftungen zählen die Haftpflicht des Motorfahrzeughalters ([Art. 58 ff. SVG](#)), die Haftpflicht der Eisenbahnunternehmung ([Seite 211](#)) (Art. 1 ff. EHG), die Haftpflicht des Luftfahrzeughalters ([Art. 64 ff. LFG](#)), die Haftpflicht der Inhaber einer Kernanlage ([Art. 3 ff. KHG](#)) und die Umwelthaftung (Art. 59a, 59b USG; vgl. die Aufzählung weiterer Gefährdungshaftungen bei REY/WILDHABER, N 1513 ff.; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 54.19).

III. Konkurrenzen

Besteht zwischen den beiden Parteien schon ausnahmsweise vor dem schädigenden Ereignis eine Rechtsbeziehung in Form eines Vertrages, so können Ansprüche **11** sowohl nach Vertrags- als auch nach Deliktsrecht geltend gemacht werden. Es besteht zwischen vertraglichen und deliktischen Ansprüchen daher **Anspruchskonkurrenz** (vgl. [BGE 120 II 58 E. 3a](#); SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 5.03; [BSK OR I-KESSLER, Art. 41 N 2](#)). Diese Anspruchskonkurrenz besteht unbestritten zwischen der Vertragshaftung auf der einen und der Verschuldenshaftung gem. Art. 41 Abs. 1 sowie den einfachen Kausalhaftungstatbeständen auf der anderen Seite (vgl. [BGE 113 II 246 E. 3](#); REY/WILDHABER, N 51 m.w.N.). Anspruchskonkurrenz hat aber auch zwischen der vertraglichen Haftung und den Gefährdungshaftungen zu bestehen (SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 54.04; REY/WILDHABER, N 55, 1248; OPTINGER/STARK, I, § 13 N 44). Die praktische Bedeutung der Anspruchskonkurrenz zeigt sich insb. bei den unterschiedlichen Haftungsmodalitäten, wie hinsichtlich des Verschuldenserfordernisses, der Beweislast für das Verschulden oder der Verjährung (vgl. hierzu z.B. REY/WILDHABER, N 54; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 5.04). Die Anspruchskonkurrenz zwischen Vertrags- und Deliktshaftung ist keine

Selbstverständlichkeit, so geht bspw. das französische Recht von einer Exklusivität des Vertragsanspruchs aus (Prinzip des *non cumul*).

Grundsätzlich beeinflusst die Anspruchskonkurrenz zwischen Vertrags- und Deliktsanspruch die Haftungsmodalitäten damit. So folgen die jeweiligen Ansprüche i.d.R. (vgl. jedoch die neue Best. von Art. 128a) einem eigenen Verjährungsregime (vgl. z.B. zur Nichtübertragung der relativen Verjährungsfrist gem. Art. 60 Abs. 1 auf einen konkurrierenden Vertragsanspruch **BGE 87 II 155 E. 3a**). Demgegenüber ist eine Veränderung des Deliktsanspruchs durch das konkurrierende Vertragsrecht in Einzelfällen möglich (vgl. OFTINGER/STARK, I, § 13 N 59 ff.; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 5.05). Dies betrifft zum einen gewisse **Haftungsmilderungen** für bestimmte Vertragstypen, wie die Beschränkung einer Haftung auf grobe Fahrlässigkeit und Absicht (so z.B. Haftung des Schenkers, Art. 248 Abs. 1; vgl. weitere Bsp. bei OFTINGER/STARK, I, § 13 N 61). Zum anderen können **vertraglich vereinbarte Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen** auch auf das Deliktsrecht durchschlagen. Ob ein gültiger Haftungsausschluss in jedem Falle auch den Deliktsanspruch erfasst, ist bisher zwar noch nicht endgültig geklärt worden. Die h.M. bejaht dies jedoch ausserhalb von Personen- und Umweltschä **[Seite 212]** den (vgl. etwa MÜLLER-CHEN, Haftungskonzept, 17; BK-BREHM, **Art. 41 OR** N 230a ff. je m.w.N.).

Erfüllt ein Sachverhalt die Voraussetzungen mehrerer ausservertraglicher Haftungstatbestände, so wird zwischen verschiedenen (einfachen oder strengen) Kausalhaftungen Anspruchskonkurrenz angenommen (vgl. **BGE 115 II 237 E. 2a**; diff. OFTINGER/STARK, I, § 13 N 20 ff.). Nach bundesgerichtlicher Rsp. gilt dies jedoch nicht im Verhältnis **zwischen Kausalhaftungstatbeständen und der allgemeinen Verschuldenshaftung** gem. Art. 41 ff.; in diesem Bereich gilt eine **Exklusivität der Kausalhaftungen** (**BGE 115 II 237 E. 2a**). Nach einem älteren Teil der Lehre gilt der Grundsatz der Exklusivität der Gefährdungshaftung auch im Verhältnis zu anderen einfachen Kausalhaftungen (OFTINGER/STARK, I, § 13 N 32). Diese stellt insb. dann ein Problem dar, wenn der Schutzbereich der Gefährdungshaftung geringer ist als derjenige der allgemeinen Verschuldenshaftung, bspw. durch Ausschluss gewisser Schadensarten im Rahmen der Gefährdungshaftung (vgl. so im Zusammenhang mit **Art. 58 Abs. 1 SVG, BGE 106 II 75**). In diesen Fällen ist im Einklang mit der neueren Lehre daher Anspruchskonkurrenz zwischen Gefährdungshaftungen und allg. Verschuldenshaftung anzunehmen (SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 49.12; KRAMER, 128, 129 ff.; LORANDI, recht 1990, 19, 20 f., REY/WILDHABER, N 59). Dies ist im Übrigen auch die in **Art. 11 Abs. 2 PrHG** festgelegte Lösung.